

澳門大學
法學院
中文法學士課程(晚間)
2013/2014 學年度(上學期)

講師：蕭偉志

I-學習大綱。

*

執行之訴。

I-引言。

- A.教授科目之課程大綱及方法。
- B.教科書及學習材料。
- C.適用法規。
- D.理論及實踐的重要性。

II-執行之訴之一般理論。

A. 執行之訴之概念及目的。

- 1. 民事訴訟之一般分類。
- 2. 執行之訴之法定分類以及每一種類及目的。

B. 執行之訴之訴訟前提。

- 1. 一般及專門之訴訟前提。
- 2. 執行之訴之專門前提及分類。
- 3. 形式前提－執行名義。
 - a.一般概念。
 - b.法律性質。
 - c.執行名義之分類。
 - i)法院發出之執行名義。
 - ii)非由法院發出之執行名義。

d.欠缺執行名義或不具執行力之後果。

e.宣告之訴之不當使用。

4. 實質前提。

a. 債之確定及可要求履行。

b. 債之確切定出。

C-執行之訴之一般訴訟前提。

1. 列舉。

2. 法院之管轄權。

3. 當事人之正當性。

a. 誰人具正當性成為執行人及被執行人。

b. 欠缺正當性之後果。補救方法。

4. 眾數之當事人。

a. 共同訴訟。

b. 執行人或被執行人之聯合。

c. 未遵守必要共同訴訟或非法聯合之後果。

5. 在法院之強制代理。

D.執行之訴之訴訟形式。

1. 執行之訴之種類及形式。

2. 執行之訴各種類型及形式之法定制度。

E.執行之訴之移轉。

1. 支付一定金額之普通執行程序—通常形式。

a. 適用之範圍。

b. 各階段之順序及作用。

c. 訴辯書狀階段。

i) 最初聲請之形式要件及內容。

ii) 法官之初端批示：初端駁回之依據及部分初端駁回。

iii) 傳喚被執行人。

iv) 反對方法及依據。

- d. 查封之階段。
 - i) 概念。
 - ii) 標的。
 - iii) 不可查封的法律依據及其範圍。
 - iv) 查封之延伸。
 - v) 查封階段的程序。
 - vi) 查封之作用及後果。
 - vii) 查封之反對方法及依據。
 - viii) 查封之解除。
- 2. 債權人之傳召及債權之審定。
 - a. 概念及目的。
 - b. 規範債權人之法律依據。
 - c. 要求清償債權及審定。
 - d. 傳召債權人之程序。
- 3. 支付之階段。
 - a. 支付之方式。
 - b. 金錢交付。
 - c. 查封財產之判給。
 - d. 查封財產之收益用途之指定。
 - e. 以透過變賣所查封之財產之收益進行支付。
 - i) 變賣之方式。
 - ii) 優先權。
 - iii) 變賣之後果。
 - iv) 變賣非有效之情況。
 - v) 對債權人之支付。
- 4. 執行之消滅。
 - a. 執行之消滅之原因。
 - b. 執行之撤銷及重新進行已終止之執行程序。
- 5. 支付一定金額之普通執行程序－簡易形式。
- 6. 交付一定物之普通執行程序。
 - a. 通常形式。

- i)適用範圍。
- ii)程序。
- iii)執行之轉換情況。
- b.簡易形式。

7.作出事實之普通執行程序。

- a.適用範圍。
- b.程序。
 - i)作出積極事實之執行。
 - ii)作出消極事實之執行。

II-教科書及學習材料。

*

A-DIREITO PROCESSUAL CIVIL II, Dr^a Cândida da Silva Antunes Pires.

B.

- 1)民法典。
- 2)民事訴訟法典。
- 3)商法典。
- 4)公證法典。
- 5)法院之訴訟費用之制度。

III-參考書目：

*

1. Curso de Processo de Execução, Dr. Fernando Amâncio Ferreira, 2005, 8^a edição.

2.ALBERTO DOS REIS, Professor Doutor José

- a) “Código de Processo Civil Anotado:”, 6 vols;
- b) “Comentário ao Código de Processo Civil”, 3 vols;
- c) “Processo de Execução”, 2 vols;
- d) “Processos Especiais”, 2 vols,. (Coimbra Editora, Lda).

3.ANSELMO DE CASTRO, Professor Doutor Artur

“A acção executiva singular, comum e especial”(Coimbra

Editora, Lda, 1997).

4.ANTUNES VARELA, Professor Doutor João de Matos

“Manual de Processo Civil”(pp. 73 a 96) (Coimbra Editora, Lda, 1985).

5.CASTRO MENDES, Professor Doutor João de

“Direito Processual Civil”, 3º vol., (Edição da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1986)

6.LOPES CARDOSO, Dr. Eurico

“Manual da Acção Executiva”(Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 1986)

7.RODRIGUES BASTOS, Dr. Jacinto

“Notas ao Código de Processo Civil”(vol. IV), Lisboa 1984.

8.LEBRE DE FREITAS, Professor Doutor José

“A Acção Executiva- À luz do Código revisto”- 2.ª edição, Coimbra Editora, 1997.

9.Viriato Manuel Pinheiro de Lima

“Manual de Direito Processual Civil”- 2ª edição, (Tradução em 2008)

民事訴訟法 II

執行訴訟

教材

第一章

引言

（無提及屬何法規之法律規定為民事訴訟法典中之規定）

1. 執行之訴之概念

1.1 執行之訴之法律定義

載於民事訴訟法典第 11 條第 3 款之定義為：「執行之訴係指原告請求採取適當措施以確實彌補遭受侵害之權利之訴訟」（執行措施—意大利人稱為強制執行）。

1.2. 執行之訴之結構

宣告之訴之結構為一審判之結構，主要表現在裁決，解決爭議及問題，然而，執行之訴之結構為於事實之層面實現裁決之實質結果，且主要表現在下列之行為：從債務人之財產處取走一些物（查封）；交付；強制變賣後以變賣之價金作出支付，或以變賣之所得之價金支付作出事實之支出。

1.3. 執行之訴之法定制度

執行之訴由該訴訟之專門規定所規範，其中包括民事訴訟法典第 11 條第一款及第三款（訴訟種類）；第 12 條（執行名義之作用）；第 677 條至第 836 條（執行名義）；執行之初步階段及各執行程序之種類之步驟）；第 21 條至第 25 條之規定（執行事宜上之管轄權）；

第 68 條至第 71 條（執行事宜上之正當性）；第 74 條第 1 款 c 項及 d 項及第 5 款（律師之強制委託）；第 161 條（分發之第 5 類別）；第 374 條及第 375 條（执行程序之形式）；此外，亦受民事訴訟法典之一般及普通規定所規範：最後，根據第 375 條第 1 款之規定，亦補充適用規範宣告之訴之規定。

第二章

執行之訴之前提

專門前提

形式前提：執行名義（民事訴訟法典第 12 條、第 677 條至第 683 條）。

實質前提：債（確定的、可要求履行的一可執行的一以及已確切定出的：民事訴訟法典第 686 條至第 694 條。

2. 形式前提：執行名義。

2.1 執行名義之概念。

如起訴人不具備執行名義，則不可提起執行之訴——民事訴訟法典第 12 條：「執行之訴係以一執行名義為依據，其目的及範圍透過該執名義予以確定」。

2.2 執行名義之法律性質

* CASTRO MENDES 教授：作為形式前提，可將執行名義定義為「因提供在法律上對某給付具有權利之足夠證明，故可根據法律作為該權利之執行依據之文件」；作為實質前提，「為證明存有執行權利之法定工具」，「嚴格來說，非主要及必要地一行為，亦非主要及必要地屬一文件」（《民事訴訟法》，第三冊）。

* LOPES CARDOSO 大法官：「執行名義為訴因」，為取得權利之依據。

* 執行名義是一書面文件(具有文件，方具有執行名義)。

* 執行名義為必要條件(具有執行名義，方得進行執执行程序)；且執行名義為足夠條件(因透過執行名義推定存有債)；至少為提起執行之訴之必要及足夠之條件。

2.3 執行名義之作用

第 12 條規定：「執行之訴係以一執行名義為依據，而其目的及範圍透過該執行名義予以確定。」

* 執行名義使執行之標的具體化。

* 確定執行之訴之範圍

* 透過載於執行名義之給付定出執行之訴之種類或類型。

* 執行之訴之目的為向債權人提供如債務人自願及自發履行時向其提供之相同效果。

* 由於債權人因執行名義之證明效力而得益，故執行名義亦具有證明作用(一方面);且另一方面，亦具有形成作用，意思為執行名義給予執行之訴生命，使之可具體地成為訴訟。

2.4 執行名義之要件。

* 執行名義等同文件。

文件賦予擁有該文件之占有人取得之正當方法，且文件有使本身具法律效力所必須之特定方式時，方存有執行名義；

* 債之存在

根據民事訴訟法典第 677 條 a 項及 c 項、第 679 條第 1 款及第 681 條規定所得出之結論，在執行名義中必須載明存有可請求之債。訴訟開始時無須任何存有該債之補充證明。僅在該債透過異議遭受反駁時，方須透過法律容許之其他證據對執行名義所載之證據予以補充；

* 債之可要求履行性

執行名義之執行作用為提供予負責執行之機關(法院)有關權利之法定證據，亦即是說，具有應債權人之請求形成執行之訴之作用。執行之效力之目的為給予債權人一個可讓其最快及最完整地滿足其債權之方法。

2.5. 執行名義之種類(民事訴訟法典第677條)

- A. 給付判決；
- B. 經公證員作成或認證之文件；
- C. 經債務人簽名，導致設定或確認按第689條確定或按該條可確定其金額之金錢之私文書，又或導致認定或確認屬交付動產之債或作出事實之債之私文書；
- D. 按特別規定獲賦予執行力之文件。

從第677條開始之句子：「僅下列者可作為執行依據」，可得知上指規定為盡數列舉。換句話說，僅法律所指明之書面文件，方為執行名義(在民事訴訟法典中或其他法規中指明者)。

A · 給付判決

* 給付判決為所有包括給付命令之法院裁判，不論該裁判是否

於給付之訴中作出者亦然(包括第699條第2款指出的和解之認可判決)。

* 判決之概念:民事訴訟法典第106條第2款。

* 司法當局判處履行一債務之批示以及判處履行一債務之其他裁判或行為，於執行力角度上，等同於判決(第679條第1款)。

* 仲裁庭所作之裁決如普通法院(永久審判權)之裁判般屬予以執行(第679條第2款)。

* 如清理批示直接審理請求或永久抗辯(第429條第1款b項)，由於具有執行力，亦納入第677條a項之規範中。

* 可執行之批示中亦包括根據民事訴訟法典第385條至第388條之規定所裁定作出損害賠償之批示，以及訂定服務費或鑑定人的報酬之批示b及裁定罰款之批示等。

* 外國法院或仲裁員所作之裁判，經澳門具有管轄權之法院審查及確認後（第1199條及隨後規定），亦可作為執行名義(第680條第1款)。但嚴格上，在該等情況下，實際上，作為執行依據者為具管轄權法院所作之 確認性之合議庭裁判。

A. 經公證員作成或認證之文件

根據公證法典第50條第2款之規定中所定義之文件，而該款中所指之公文書為：公證員在有關簿冊或獨立文書內繕立之文書，以及由公證員發出之證明書、證明及其他類似之文書。

因此，僅透過公證確認筆跡及簽名或只確認簽名之文件不包括在內。

故此，不論是在記錄簿冊中作成之公證書及公證遺囑（公證遺囑及法律要求以公證書作成之行為，或利害關係人欲透過該嚴謹之方式作成之行為），又或是非於記錄簿冊中作成之文書（應載於公文書之行為，但法律或當事人無要求以公證書作成者），均屬可執行者。

（注意——於澳門，僅公共公證員可作成所有類型之公證書，且只能由其作成公證遺囑。私人公證員僅具有權限作成某幾類公證書）。

B. 其他私文書

為使具有執行力，文件必須形成或證明存有一債務，而學理上，認為預計設定一債務並不足夠。因此，有訂定不履行任何合同義務時之懲罰性條款之私文書不構成所設定之有關損害賠償或懲罰性條款

之金額之執行名義，因該文書無提供設定有關債務之證據。

因此，為確認一私文書具有執行效力，其必須符合下列各實質要件；

- * 證明存有一法律上之行為，且透過該行為，某人對他人負上債務；

- * 該債務為支付按第689條確定或按該條可確定之一定金額，或交付動產，或作出積極或消極事實之給付；

LOPES CARDOSO大法官接納透過侵權書在私文書上簽名之可能，並不使該等文書失卻執行效力；只要委託之關係載於上述文書中，至少須在受託人之簽名前提及委託之關係，且可透過常用之縮寫：「P.P」（透過授權書）為之。

C. 在特別規定中規範之文件

按特別法律規定獲賦予執行力之文件。

例如：

* 帳目或訴訟費用、罰款及損害賠償之證明書(民事訴訟法典第376條至 第388條);

* 本在提交帳目之特別訴訟程序中，民事訴訟法典第882條第4款中規範之可能情況。

* 澳門民法典第1014條第3款及第4款及第1015條規定之文件。

2.6. 欠缺執行名義或不具執行性之後果。

不具執行名義而提起執行之訴時有何法律上之問題?

法官收到一個並無連同執行名義之聲請時應作何種批示?

某些學說上之意見:

* JOSE ALBERTO DOS REIS教授:

法官應初端駁回有關聲請。

第394條第1款d項(請求之不可行):「因其他理由,原告之主張明顯不能成立時」(第394條透過第375條第1款之準用而適用)。

* LOPES CARDOSO大法官:

從其認為執行名義為執行之訴中之訴因這一見解出發,由於欠缺訴因,因此,其應堅持因聲請書不適當而初端駁回聲請;第139條第2款a項及第394條第1款a項。

然而,其贊同ALBERTO DOS REIS教授之論點,認為須初端駁回聲請,且以原告之請求不可行為依據。

* CASTRO MENDES教授:

其認為第394條所列出之情況屬盡數列舉之規定,且應對抗透過使用「不可行」這理據之趨勢(第394條第1款d項),倘初端駁因為最合理之解決方法。

狹義之不可行為一實質上之瑕疵,與請求之理由不成立有關;而欠缺執行名義,或其為不具執行性之情況屬程序上之瑕疵。

因此，欠缺執行名義時，聲請因無附同一必要之文件而屬不當之聲請，故應作出補正批示(透過民事訴訟法典第375條第1款;而適用之第397條)。

2.7. 執行名義與執行請求之不一致

如在最初聲請中所提出之請求與執行名義不一致時有何法律上之問題?

可分為主體上之不一致及客體上之不一致(可與執行之訴之當事人有關或與執行之標的有關)。

* 主體上之不一致:針對非為執行名義內所載之人士提起執行之訴(不具正當性之當事人:民事訴訟法典第68條第1款)。

CASTRO MENDES教授:

如當事人明顯不具正當性，起訴狀應被初端駁回(透過第375條第1款之規定而適用之第394條第1款c項)。

* 客體上之不一致:請求質量上或數量上非為執行名義中所載之情況。

CASTRO MENDES教授將之分為絕對客體上之不一致及相對客體上不一致

* 如執行名義絕對不能作為請求之依據時出現第一種不一致之情況(例如:透過執行名義,債務人欠「珠寶X」,但請求執行「畫Y」:如屬此情況,應適用與欠缺執行名義相同之解決辦法,即是說,作出補正批示(透過民事訴訟法典第375條第1款之規定適用之第397條)。

* 如僅屬相對之不一致,申言之,提出之請求超過執行名義所載者時,屬相對之不一致情況。正如第394條第2款只規定單一請求之情況,如請求執行之人將兩個或以上之請求合併,法官須請其提交未載於執行名義中之請求之執行名義(第397條);如請求執行之人不在指定之期間內提交,法官應駁回該等請求,並就有依據之請求命令傳喚被告。

如僅有一個請求,但從執行名義中得知債務人欠一百,而請求執行之人要求二百,則法官應傳喚被執行人,以便其按因應情況,以第696條至第699條之規定提出異議。

在任何情況下均不可能有部份初端駁回,並透過民事訴訟法典第375條第1款之規定適用第394條第2款之規定。

LOPES CARDOSO大法官認為如請求與執行名義間之不一致是由於執行請求過度,駁回得只限於超過執行名義內容之部份,且命令執行之訴按正確之數額繼續進行。

其認為第394第2款不適用於執行之訴，因此，根據法律規定，可作出部份初端駁回。

3. 實質前提:執行之債務

3.1. 確定及可要求履行

透過執行之訴，債權人欲以代位之方法就給付及/或因不履行該給付之損害賠償強制作出支付；為使請求可得到滿足，執行之債務必須：

- 存在／繼續存在；
- 處於不履行之狀況(遲延之情況)；
- 關於一定之給付。

債權人有負擔透過執行名義證明存在有關債務，而按法律之規定，該債務須為可要求履行者。

至於債務人，其有負擔證明該債務已不存在，例如，因為已履行該債務，且透過被執行人異議(第696條及隨後規定)反對有關之執行。

但法律亦規定例外情況：作出消極事實之執行之訴正由發現不履行時開始——見民事訴訟法典第834條第1款。

執行之訴必須以存在一債務為基礎，且須為一可予以執行之債務，即是說，可評估其給付、確定及可要求履行之債務（第686條至第688條）。

所要求的是債務須確定及已到期，此為具有作為執行之訴正常運作之（實質）要件——執行之債務之特徵。

3.2. 民事訴訟法典第686條至第688條中包括之債之特別類型

A. 不可請求履行及未到期之債

在宣告之訴中可裁定給付不可請求履行之債（第393條第1款及第565條）。與宣告之訴相反，在執行之訴中，執行之債務必須為可請求履行者（第686條至第688條）。

不可請求履行之債為仍未到期之債或取決於停止條件之債，其可出現下列情況：

* 因期限仍未屆滿而導致債之不可請求履行；

* 因欠缺催告（對於單純之債務）而導致債之不可請求履行；

* 因債權人或第三人一方不作給付，又或未符合條件（第 688 條第 1 款）而導致債之不可請求履行。

C. 選擇之債及種類之債

債之不確定，主要出現在選擇之債（民法典第 536 條第 1 款）及種類之債（民法典第 532 條及隨後規定）。

必須對該等債務作出選擇或列明，方可進行執行之訴。

對於選擇之債之執行性，可視乎選擇權屬誰人而分為下列情況：

一如選擇權原本屬於債權人，

債權人必須在執行前作出選擇，並將之載於最初之聲請中，以及提出一確定之請求。

由於屬一接受性之聲明，故此僅透過對被執行人之傳喚為之。僅透過該傳喚方可視為存有催告，故債亦因此到期（民事訴訟法典第 688 條第 3 款第 565 條第 2 款 b 項）。

同樣地，僅透過對被執行人之傳喚，方確定有關之給付。

這樣將得出如下結果：如被執行人在法院指定履行之期間內履行，則須視作非因被執行人之故而引致執行之訴，因為在其被傳喚前，有關債務仍未到期，仍未確定，故此不可能被履行。因此，須由執行人（非由被執行人）負責執行之訴之訴訟費用。

--如選擇權屬第三人，

民法典第 542 條及民事訴訟法第 687 條第 3 款指出由第三人指定給付之情況；得出現如第三人不作出給付選擇，則由法院根據民事訴訟法典第 1219 條之規定，指定有關給付。

--如選擇權屬債務人

適用民事訴訟法典第 687 條第 1 款：須「… … 通知在法院指定之期間內聲明選其選擇作出之給付」。

第二款：「無作出聲明時，則執行得按債權人所選擇之給付為之。」

如執行名義中所載之債務為選擇之債，且選擇權屬債務人，則須作出第 687 條所提及之初步訴訟活動。

該行為是執行之初步階段所作之司法通知（相同條文第 1 款），但已不屬舊法典所規定的訴訟以外之通知。

C. 未確切定出之債。結算。

未確切定出之債係標的為未以數字確定指明數量之債務，且標的之給付金額存有不確定性。例如：債務人必須支付其所造成之損失，又或以澳門圓支付相當於一千英磅之價金等之情況。

給付之金額確定時，債務為已確切定出之債。

執行未確切定出之債之可能與在執行之訴中提出未確切定出之請求之可能是不同之事情。

僅在非常有限之情況下可提出未確切定出之請求：可在執行之訴之聲請中提出執行包括在訴訟中繼續到期之利息之請求，而有關利息

須按第 689 條第 2 款之規定結算（最終由法院辦事處作出）。

在民事訴訟法典第 392 條中將上述請求稱為概括性請求。按照該條之技術分析，在執行之訴中仍存有另一類之概括性請求：根據第 392 條第 1 款 a 項之規定，透過法院要求交付事實或權利之集合物。例如，如在執行名義載明債務人必須交付一群家畜，則相應之執行須為交付該一定物，而該一定物為一集合物。

除該等情況外，必須提出一已結算及確定之請求。

如屬已確切定出之債，則只是證明之問題；如屬未確切定出之債，則必須作出相關結算。

結算可由請求執行之人本人作出、由法院作出或由仲裁員作出。

在第 689 條第 1 款規定之情況下，即是說，「結算僅取決於簡單之數學計算時」，由請求執行之人在執行之訴之最初聲請中作出結算。

除此之外，通常由法院作出結算（第 690 條），在例外之情況下亦由仲裁員進行結算（第 693 條），但均須在執行之訴之初步階段內進行（初步階段已是執行之訴之一部份）。結算亦可稱為結算程序，由於其用作調查一定之事實，故此具有宣告之訴之性質。

* 由法院結算：

執行之訴自最初之聲請開始。於最初之聲請中，請求執行之人須指出其認為給付所包括之利益值（結算之條文），而該聲請應以一確定請求作終結。

須傳喚被執行人就結算作出反駁（第 690 條第 2 款）

如其不作反駁，則按規定「有關之債視為按請求執行之人所作之聲請訂定。（因此，不就結算作反駁時產生不作反駁之完全效果），並「命令繼續進行执行程序（第 691 條第 3 款），似乎無需由請求執行之人重新提出聲請。

執行之訴繼續進行是透過對被執行人作出通知為之，而該通知根據第 695 條第 2 款作出，目的是通知被執行人支付或指定戶以查封之財產（屬支付一定金額之執行的情況）。

如被執行人作反駁，則「按簡易宣告訴訟程序中作出反駁後之步驟處理」

就結算作出裁判之判決應命令執行之訴繼續進行，即是說，對被執行人作出通知。

* 由仲裁員結算

在第 693 條規定之情況下由仲裁員進行結算。而該條文亦規範此機關之運作—其具有進行債之結算之專門任務。

在該等情況下，仲裁員之決定或專門意見須經法官認可，與對待一般仲裁庭之裁決不同。

第三章

一般之訴訟前提在執行之訴中之特殊情況

4. 法院之管轄權

4.1 秩序之原因。新法定制度。

管轄權這訴訟前提由澳門新民事訴訟法典第 13 條至第 38 條之規定規範，第一章載有“一般規定”（第一節）“執行事宜上之管轄權”（第二節），而其它兩章載有“管轄權之延伸及變更”及“管轄權之保障”。

於第 15 條至第 20 條上，規範澳門法院在其它管轄區前擁有的管轄權，申言之，界定作為整體之澳門法院，如何擁有條件使其具有管轄權，審理與數個法律秩序具有聯繫之事宜。

不屬這裡分析上述規定，因為該等規定已被不同種類之宣告之訴所討論，不論為一般程序或特別程序及保全程序，這全屬第三年科目之民事訴訟法 I 之教程。但正如上述所指，載於第一章之第二節負責規範“執行事宜上之管轄權”，而這種訴訟構成第四年之民事訴訟法 II 之教程之專門標的。

因此，我們將分析第 21 條至第 25 條之規定，這等同被新法典最近廢止之法典第 90 條至第 95 條。

相對於舊制度，不存在任何重要修改，而亦看不出任何理由不繼續有關制度——正如發生在舊法典之生效期內——第 13 條（規範管

轄權之法律）及第 14 條（轉移之禁止）等一般規定被視為適用於執行之訴上。

從第 21 條至第 25 條之規定上，得出不同澳門法院之內部分配權限之規則：

1. 以澳門法院所作之判決為依據之執行，由審判案件之第一審法院管轄（第 21 條第 1 款），“但本法典另有規定者除外。”

2. 以內部仲裁員所作之判決（第 21 條第 2 款）、上級法院所作之裁判（第 22 條及第 23 條第 3 款）、澳門以外地方之法院或仲裁員作出之裁判（第 24 條）為依據之執行，由第一審法院管轄。

3. 最後，新法典第 25 條規範賦予澳門法院管轄權之兩個規定，該等規定總體上關於以有別於上述執行名義為依據之執行之訴。根據第 25 條之規定，澳門法院具管轄權審理：

a) 交付一定物之執行或設有物之擔保之債務之執行，而該一定物或附有負擔之財產在澳門；及

b) 其它執行，倘有關債務應在澳門履行。

當然，第 25 條之規定假設將來司法制度之綱要法，規範能界定澳門

具體具有管轄權之法院之規定。

5. 當事人之正當性。形式上之正當性

執行之訴關於正當性之一般規則載於民事訴訟法典第 68 條及第 69 條第 1 款之規定中。

誰為正當之當事人：

1--在執行名義中作為債權人及債務人（第 68 條第 1 款）及其繼受人（第 68 條第 3 款）（繼受人通常透過確認資格此附隨事項參加有關訴訟程序）

2--「具有負擔之財產之第三者占有人」亦為具正當性之當事人（第 68 條第 4 款及第 5 款）

3--判決對其構成裁判已確定之案件之第三人（第 69 條）

4--檢察院（民事訴訟法典第 70 條；以及 8 月 29 日之第 112 / 91 號法律（澳門司法組織綱要法）第 23 及 8 月 18 日之第 55 / 92 / M 號法令第 14 條），有權就任何訴訟程序中規定繳納之訴訟費及

罰款提起執行程序。

5.1 在執行名義中載明之人士及其繼承人(第 68 條第 1 款及第 3 款)

不論請求執行之人或被執行人均須載於執行名義中。然而，任一方發生繼受時，執行應由／或針對有關人士之繼受人而提起，為此，請求執行之人應在執行之訴之聲請中陳述--以及證明--繼受之形成事實（第 68 條第 3 款）。

--如繼受於提起執行之訴前發生，則免除繼受人確認資格之附隨事項。

--如繼受於執行之訴待決時發生，則須有繼受人確認資格之附隨事項。

如執行之訴以無記名證券（例：支票）為依據，則執行之訴須由該證券之持有人提起（第 68 條第 2 款）。

5.2 具有負擔之財產之第三者占有人（第 68 條第 4 款及第 5 款）

無論是以第三人之財產作擔保，或在形成擔保後將債務人負有擔保之財產轉讓之情況均屬此類情況（任一情況中財產之所有人均為第

三人)。另外，債務人為所有人，但財產由第三人占有之情況亦屬此類。

在上述各種情況中，債務人並非為作為物之擔保之財產之所有人。

對此債權人得（第 68 條第 4 款及第 5 款）：

——針對第三人提起執行之訴，且在財產不足夠時，請求傳喚債務人；或

——同時針對第三人及債務人提起執行之訴。

如僅針對債務人提起執行之訴，則不具有正當性，除非事前放棄已形成之物之擔保（民法典第 659 條；第 673 條及第 725 條 d 項）。

如債務人為用作擔保之物之完全所有人，但該等物由第三人占有者，債權人可選擇只針對債務人或針對債務人及第三人提起執行之訴。當然，在任一情況下均可查封有關物。然而，只針對債務人提起執行時，無被訴之占有人可透過第三人異議反對有關查封（第 292 條）。

5.3 判決對其構成裁判已確定之案件之第三人（第 69 條）

例子：

* 具爭議之權利之移轉

正在法院審理之權利被移轉，而取得人並無參與有關之訴訟程序時，判決對取得人構成裁判已確定之案件；

* 第三人參加訴訟（訴訟程序之附隨事項）—第 262 條及隨後規定—於第 270 條第 2 款所指之情況上，即使被召換之人不參加訴訟，該判決對其構成裁判已確定之案件；

5.4 檢察院（第 70 條，以及之前提及之澳門司法組織綱要法及 3 月 2 日之第 17 / 92 / M 號法令中之規定）

「檢察院有權就任何訴訟程序中規定繳納之訴訟費用及罰款提起執行程序（第 70 條）。

在宣告之訴中，根據第 413 條第 e 項之規定，不具正當性屬延訴抗辯，而按第 414 條之規定依職權審理，且屬明顯不具正當性時，根據第 394 條第 1 款 c 項之規定，應導致初端駁回。

6. 在法院之代理之強制性（第 74 條）

僅在利益值超過中級法院之法定上訴利益限額時，方必須在執行之訴中委託律師。

在被執行人異議之訴訟程序中，只要利益值高於第一審法院之法定上訴利益限額，則必須委託律師。

在請求清償債權及審定債權之訴訟程序中，只要審理之債權之金額高於第一審法院之法定上訴利益限額，則必須委託律師。

對於上訴之事宜，由於第 74 條第 1 款 b 項規範。

7. 眾數之當事人及執行請求

* 在宣告之訴中，（一個或數個）請求對於所有參加者來說均相同時，則存在共同訴訟之情況。數名原告針對一名或數名被告提出不同之請求時，則存在聯合之情況。

聯合與眾數之主體以及眾數之請求之情況聯繫在一起。

* 在執行之訴，所請求之給付相同，但具數名參加人時，則存在共同訴訟之情況。一名或數名債權人要求一名或數名債務人作

出不同之給付時，則存在聯合之情況。

7.1 共同訴訟

普通共同訴訟：執行之訴可由一名債權人提起或針對一名債務人提起，但亦可由數名債權人提起或針對數名債務人提起：第 60 條。

7.2 聯合（第 71 條）

* 原告一方之聯合（請求執行之人一債權人）：針對一名或數名被執行人。

* 被告一方之聯合（被執行人）：僅由一名請求執行之人針對數名債務人提起。

* 原告及被告之聯合：請求執行之人及被執行人之數目為眾數。

--聯合之前提：

* 各執执行程序具有相同目的（第 71 條第 1 款 b 項）；

* 倘屬金錢債務，必須為已確切定出之債務，或可透過簡單之數學計算定出之債務（第 71 條第 2 款）；

* 相同法院具管轄權審理所有之請求（第 71 條第 1 款 a 項）；

* 所有請求均按相同之訴訟形式進行訴訟（所有按普通或特別訴訟程序。屬特別訴訟程序時，按相同之特別訴訟程序—第 71 條第 1 款 c 項）。

* 被告一方之聯合中，對於所有之債務，執行應以相同之執行名義為依據。

--聯合之違法；後果：

a)初端駁回。

經作出必要配合後，第 375 條第 1 款準用第 394 條

不論何種執行名義，聯合之違法一定為被執行人異議之依據：第 697 條、第 698 條第 1 款及第 699 條第 1 款。

7.3 請求之合併（第 684 條及第 685 條將之稱為執行之自始合併及執行之繼後合併）

a)執行之自始合併：在提起執行之訴時作成之合併。

前提：第 684 條準用第 71 條

* 各請求之執行目的均一致（支付一定金額或交付一定物，又或作出一事實）；

* 同一所法院具管轄權；

* 具相同之訴訟程序（普通或特別，而屬後者時，須具相同之特別訴訟程序）

b)執行之繼後合併：在已提起之執行之訴待決時，請求執行之人在相同之訴訟中提出新之執行請求（第 685 條）。

前提：

* 執行之目的與法院之管轄權：適用執行之自始合併的制度。

* 訴訟形式：待決之執行之訴訟形式（特別；通常或簡易訴訟程序）及請求合併後所導致之訴訟形式必須一致。

補充部分

A、B及C共同向D借款 60 萬元，後來，A以書面確認上述欠款，而B及C則透過給付判決被判處上述欠款之責任。

Castro Mendes:

D不可在同一之執行訴訟針對A、B及C，此因為A、B及C雖處於共同訴訟之關係，但，是以不同的執行名義。

Lopes Cardoso:

對，但上述非屬聯合之情況，而屬執行之合併，(所請求之給付相同，被執行人具連帶責任)故須符合<<民事訴訟法典>>第 684 條之規定，而非第 71 條之規定。

因為在兩份執行名義中債務人均非屬同一組的，此乃妨礙債權人D同時執行B、C這組債務人及A債務人的原因。(看<<民事訴訟法典>>第 684 條)

倘債權人D與另一債權人E一起執行B及C這一組債務人，而該組債務人在其中一給付判決中被判處以連帶責任向D作出一定金額之給付，又以連帶責任在另一判決中一起被判向E作另一給付時才出現請求執行人之聯合。

第 374 條使執行之訴訟形式取決於執行名義之性質，欲預防因合併而引致訴訟形式之改變。

c)不適當合併之後果:

正如聯合之違法般，具有相同後果。

對於執行之繼後合併，法官須於就請求執行之人之聲請所作之批示中予以駁回。

如接納合併，則通知被執行人，其可對被合併之請求提出異議。

第四章

執行之訴之訴訟形式

8. 普通或特別訴訟程序

根據第 369 條之規定（包括一般規定，因此，適用宣告之訴及執行之訴），法律指出訴訟程序可分為普通訴訟程序或特別訴訟程序，而特別訴訟程序適用於法律明文指定之情況。普通訴訟程序適用於所有不採用特別訴訟程序之情況。

因此，普通訴訟程序被訂定為一種補充之訴訟形式，所有並沒有在本法典第五卷特別規定作為特別訴訟程序之情況，均須按普通之訴訟程序進行。

8.1 普通訴訟程序

普通訴訟程序按執行之訴之目的分為三大種類或類型，且其在第 375 條中明示載明（亦見第 12 條第 2 款）：

-- 支付一定金額之執行之訴；

-- 交付一定物之執行之訴；

-- 作出一事實之執行之訴。

執行之訴之主要（典型）類型為支付一定金額之訴訟。所有其他之訴訟之給付不可能履行且有需要透過支付同等價值以替代時，則按該種訴訟形式處理。另外，從第 375 條第 2 款中得知，支付一定金

額之執行以補充之方式適用於其他類型之執行之訴。

8.2 特別訴訟程序

一些例子：

訴訟費用之執行（法院訴訟費用制度，由 1 999 年 10 月 21 日第 63 / 99 號法令核准，刊登於同一日第 43 期政府公報）；

扶養之特別執行：民事訴訟法典第 958 條及隨後數條；

勒遷之訴之執行階段：民事訴訟法典第 935 條至第 937 條。

9. 通常及簡易之訴訟程序

除前述之訴訟形式外，還須考慮另一種分類之規定。該種分類於宣告之訴上主要按利益值為之（參閱第 371 條）。在執行之訴上，通常及簡易形式之分類透以何種執行名義為依據界定。

因此：

在下列情況以通常形式進行（第 374 條第 1 款）：

a) 執行名義為非司法執行名義

b) 倘司法執行名義（給付判決）判處履行不確切定出之債務，而該債務不僅取決於簡單之數學計算；倘執行名義為司法判決，判處履行已確切定出之債務或僅取決於簡單之數學計算而確切定出之債務，則以簡易形式進行。

使用不適當之形式時，根據第 145 條規定之效力，將導致無效，而其後果為撤銷不可利用之行為（相同條文第 1 款），除第 2 款規定之情況外。

關於各種執行之訴訟形式之制度，須考慮民事訴訟法典第 375 條之規定。

第五章

支付一定金額之執行 通常訴訟程序

僅在執行名義中載有一金錢債務時方可進行支付一定金額之執行之訴。

金錢之債（民法典第 543 條及隨後規定）可分為三類性質：

- 以法定貨幣表示之一定價值之債務；
- 特定之法定貨幣之債務（例：以面額一千澳門圓之紙幣支付）；
- 以外幣支付之債務。

首兩類透過提起支付一定金額之執行之訴予以執行；而以外幣支付之債務透過提起交付一定物之執行之訴為之。

交付一定物之執行之訴（第 821 條）及作出一事實之執行之訴（第 826 條）可轉為支付一定金額之執行之訴（分別參閱第 824 條及第 827 條）。

後者之各個時刻及執行之形式如下：

- 1°--提起訴訟：按照處分原則，債權人必須向法院辦事處提交首份之訴辯書狀（最初聲請）；
- 2°--查封：扣押債務人之財產或權利；
- 3°--強制變賣被查封之財產；
- 4°--支付（具有數種模式一參閱第 765 條）。

該四段時刻相等於四個階段：

- 1. 初步階段；

2. 查封階段：
3. 變賣階段；
4. 支付階段。

在該四個階段中可出現兩個非常重要之活動，但因執行之訴與該等行為同時進行，故其正確地說並非執行之訴之階段。

A--被執行人之異議（第 696 條及隨後規定）

於現今制度中，為反對執行之最重要及唯一方法。

其與獨立之宣告之訴一般，但因就異議之裁判對執行之訴產生影響，故與執行之訴訟程序有緊密之聯繫。

被執行人之異議通常在查封前提出，但在特別之情況下可在查封之後提出：例如第 695 條第 2 款所規定之情況。

B--召喚債權人及審定債權

作出查封後，須審查誰對被查封之財產擁有物之擔保之債權。須傳喚該等債權人，以便其欲請求清償債權時，在執行之訴訟程序中提出。然後，有關債權可被反駁。經審定確定後，須進行債權之順序排列。

11. 初步階段

最初聲請

訴訟初期之手續

初端批示

傳喚被執行之人

11.1 最初之聲請

為首份訴辯書狀。訴辯書狀必須遵守對起訴狀所要求之要件，包括以分條縷述之方式作成之規定（第 101 條第 2 款）。然而，須由法院進行結算時，請求執行之人必須於執行之最初聲請中詳細列明其認為應作之給付所包含之各數額，並於聲請之結尾部份提出確切之請求。這些情況被第 690 條第 1 款規範。將最初之聲請交予法院辦事處後，訴訟視為被提起。

最初之聲請可分為以下五部份：

--抬頭：

法院之名稱

--引言：

指明當事人及

指出訴訟之形式及類型。

--陳述：

訴因（事實及法律），指出執行名義

--結論：

執行之請求：

請求傳喚被執行人支付或指定查封之財產（第 695 第 1 款）。但並非經常是這樣：如存有物之擔保時，被執行人不會被傳喚作出支付，亦不會被傳喚指定查封之財產，其會被傳喚作出支付，否則執行之訴繼續進行並查封其物之擔保之財產，而在認定該等財產不足以達致執行之目的時，方可查封其他財產（第 719 條）

--補充說明：

案件之利益值；

附交文件（最少，必須附交執行名義）。

11.2 初步之手續

基本上與宣告之訴之手續相同：

如無指明利益值時，或抬頭有錯誤等等之情況時，法院辦事處拒收有關之最初聲請。

倘以判決進行執行之訴時，最初之聲請須以附文之方式附於宣告之訴之卷宗（第 21 條第 3 款及第 22 條第 2 款）。

最初之聲請被交到法院辦事處後，將其分發（只要執行名義非為常設法院所作之判決），然後作成卷宗，及由請求執行之人支付預付金。

11.3 初端批示

作成卷宗後，須將之送閱法官，以便其審理有關之聲請並作出批示。批示可以為：

--駁回：民事訴訟法典第 394 條（透過第 375 條之規定適用）及第 695 條第 1 款，以及民法典第 1 249 條；

--補正：第 397 條（透過第 375 條之規定適用）及第 695 條第 1 款；

--傳喚：民事訴訟法典第 398 條及隨後規定及第 695 條第 1 款。

第 399 條第 2 款之規定適用於執行之訴，申言之，法官命令傳喚被執行人之事實不妨礙法官稍後（在變賣有關財產前）審理一些須依職權審理，且可導致初端駁回起訴（第 394 條及 695 條）或執行法官主動作出之行為而執行終止（第 703 條）之情況。

按照第 412 條之規定（透過第 375 條第 1 款之規定，作出必要配合後，補充適用），在該條所指之情況下，法官應不讓訴訟繼續進行，並作出判決宣告有關訴訟消滅。

11.4 召喚被執行之人

被執行人被傳喚於 20 天內（通常訴訟程序）作出支付或指定查封之財產，而根據第 94 條之規定開始計算有關期間。然而，某些情況下以通知代替傳喚（第 695 條第 2 款）：

--在第 690 條規定之結算，以及首先傳喚被告作出結算且之後方通知被告作出支付或指定查封之財產之情況下：或

--在繼後合併之情況下，例如：

- * 具物之擔保之債務餘額之情況；
- * 第 685 條所指之情況及以簡易訴訟程序進行之情況，根據第 818 條及第 519 條之規定，首先進行查封，在此情況下不對被執行人作出傳喚，只就最初之聲請及命令查封之批示通知被執行人，以便其稍後提出防禦方法（被執行人之異議或更換被查封之財產）（第 820 條第 2 款）。

相對不到庭時將指定查封財產之權利交由請求執行之人（第 720 條第 1 款）

11.5 被執行之人之反對方法

第 696 條第 1 款：「被執行人得透過異議反對執行」

透過該防禦工具，被執行人欲妨礙請求執行之人之權利之存在，又或欲提出缺乏任何一般或專門之訴訟前提之事實。

正如舊法典般，就傳喚被執行人之批示不得提起任何上訴，因為已沒有被新法典規範，亦因為得補充適用新法典第 399 條第 1 款之規定。

被執行人之異議

欲反駁或撤銷執行名義之執行力，又或反駁執行之訴。

作為一以附文方式附於執行之訴之卷宗之真正之宣告之訴。在該異議，被執行人可陳述及證明新之事實，亦可提出法律之問題，只要其可處分者

具有結算之條文時（第 690 條），須傳喚被執行人就該學條文提出答辯。然而，如欲結算提出答辯，並提出異議，則須所有行為須同時進行，因為無論裁定異議之理由成立時，均無須審理結算之請求。正因如此，法律要求在傳喚作出結算時，須同時遞交針對執行而可能作出之反駁。

仍有另一種可能之防禦方法，其為提出執行之訴之無效。

--異議之依據：第 697 條、第 698 條及第 699 條。

--提出異議之期間：第 696 條第 2 款：

* 自傳喚或在第 695 條第 2 款規定之情況下自通知起算 20 日期間內；

* 自知悉嗣後之事實起算 20 日期間內。

一般之規定為異議不會令執行之訴中止（第 701 條第 1 款），但提出異議之人提供擔保時除外。

異議之程序步驟：

以附文之方式附於執行之卷宗之宣告之訴訟程序。

異議之請求：包括民事訴訟法典「一般規定」中之第 101 第 2 款，其直接適用執行之訴。

法官之批示：

--補正批示：第 397 條（透過第 375 條第 1 款之效力）；

--駁回批示，法典稱為駁回：第 394 條及第 700 條第 1 款（前者透過第 375 條第 1 款之效力）；

--接納批示：通知請求執行之人就異議提出答辯（第 700 條第 2 款），不答辯：第 405 條第 1 款及第 406 條。

--視乎其利益值，按通常宣告訴訟程序或簡易宣告訴訟程序之步驟進行（第 700 條第 2 款）。

--就異議作出裁判：判決（第 816 條第 1 款 b 項）【就判決得提出通常上訴】

12. 查封階段

12.1 查封之概念

查封為取走債務人一些財產之占有之行為，且該等財產由法院處分，以便法院用該等財產以達至執行之訴之目的。

透過查封，強制將查封所涉及之財產之占有轉移，但還未將所有權轉移。

12.2 查封之標的。限制。

按照第 704 條之規定，「債務人之財產中凡可予以查封，且依據實體法之規定屬用作清償透過執行予以清償之債務者，均可執行」。

實體法之準用是透過民法典第 596 條為之：

「債務之履行係以債務人全部可查封之財產承擔責任，但不影響為財產之劃分而特別確立之制度之適用。」；亦須注意民法典第 807 條及第 808 條之規定，後者規定：

「第三人之財產用作擔保債權者，又或該財產係導致債權人受到損害之行為之標的，且債權人對該行為所提出之爭議被判理由成立

者，執行權之標的得為該第三人之財產」。

另一方面，民事訴訟法典第 705 條這樣規定：

「除按特別規定獲免除查封之財產外，下列者屬絕對不可查封之財產：」 a. 不可轉讓之物或權利；

從這些規定中可得出下列結論：

a) --構成債務人財產之所有東西均可成為查封之標的物，除非屬不可轉讓之物或法律規定為不可查封之其他東西：

b) --僅在下列兩種情況下第三人之財產，方成為執行之標的：

* 對於該等財產存有用作支付所執行之債之物權時；

* 債權人之爭議權被裁定理由成立，而導致第三人須將財產返還予債務人時；

c) --規則為除被執行人之財產外，不可查封其他財產；

d) --下列者導致出現例外之情況：存有特定之財產：對債務人本身之財產形成物之擔保；以及主債務人及從債務人間之責任聯繫（對從債務人財產之查封適用民事訴訟法典第 712 條之規定）。

限制：

* 因實體法之規定而不可查封：

--民事訴訟法典第 705 條：

某些財產或權利之不可轉讓：民法典第 1 849 第 1 款及第 1042 條；須經許可：民法典第 1 548 條、第 597 條及第 598 條；

* 因訴訟法之規定而不可查封：

--絕對不可查封：第 705 條；

--相對不可查封：第 706 條、第 707 條及第 711 條。

* 補充查封：

某些部份之物或全部財產，僅可在查封被執行人的其他物或財產後，仍不足以實現執行之目的時，方可將其查封。

a)於共同擁有獨立財產或分別共有不可分割財產之情況下：民事訴訟法典第 7 10 條；

b)因應婚姻之財產制度，而得出共同財產與個人財產之間分產：民事訴訟法典第 709 條；

c)於保證情況：

* 須先查封債務人之財產後，方查封保證人之財產（民法典第 634 條，但該法典第 636 條之規定除外）。

* 在針對保證人而提起之執行中，在未盡索（執行）主債務人之所有財產前，只要保證人具依據指出檢索抗辯權，則不得查封

保證人之財產（民法典第 634 條第 1 款）。

* 即使已盡索債務人之所有財產，如保證人證明係因債權人之過錯導致債權未獲滿足，則可中止對保證人之財產之執行（民法典第 634 條第 2 款）。

* 如因保證人為判決中唯一被判處之人，而判決之執行僅針對其一人提起者，則其不可援引檢索抗辯權，因為其在宣告之訴中並無召喚債務人，而該不召喚視為放棄有關之抗辯權利；隊非其在宣告之訴中明確宣告不欲放棄有關權利。

d) -- 在同一財產內出現之補充查封（民事訴訟法典第 719 條）；

「如屬設有物之擔保之債務，而該擔保以屬於債務人之財產作出者，則無須經指定，先行查封用作擔保之財產，僅在認定該等財產不足以達致執行之目的時，方可查封其他財產。」

這包括所有物之擔保。

因此，當未能證實具負擔之物不足夠時，禁止查封其他財產。

e) -- 針對債務人之繼承人而提起之訴訟中之查封（民事訴訟法典第 711 條）。

12.3 針對違法查封之反對方法

對查封之反對被新民事訴訟法典內獨立分節規範—第 753 條及第 754 條—其被明確界定為執行程序之附隨事項。

針對違法之查封具有四種反對之方法：

- 對命令查封之批示提出通常上訴（第 817 條第 1 款 c 項）；
- 就查封行為提出抗告；
- 第三人異議（訴訟程序之附隨事項，被民事訴訟第 292 條至第 300 條規範）；
- 返還所有物之訴。

四種方法中僅前三種在執行之訴訟程序中出現，即使第三種是以附文之方式為之。

通常上訴為一般反駁存有明顯違法之司法裁判之方法。

第三人異議為專門針對按規定必須證明其違法性之查封行為之反對方法。上訴作為對違法之批示提出反駁之一般方法，只要沒被一般規定所禁止，則可提出。而專門方法—第三人異議—僅可在法律容許之情況下，方可提出。

A. 對命令查封之批示提起通常上訴

只要命令查封之批示違法則可提出抗告。違法通常是以超過「查封標的之客觀限制」之事實為依據：查封在某些情況下，或對於某債務，又或仍未盡索其他財產時，不應查封之財產。

在作出命令查封之批示時，法官可能不知悉其應審理之問題，在此情況下，批示屬無效（第 571 條第 1 款 d 項及第 569 條第 3 款）

B. 就查封行為提出抗告（第 716 條）

法律規定僅被執行人有權使用該方法（或某人以其名義），且該方法僅限於直接適用在主體及客體方面之外在不可查封方面之範圍。

C. 第三人異議（訴訟程序之附隨事項—第 754 條及第 292 條及隨後規定）

1. 在下列情況下，可提出第三人異議：

* 對於本人名義占有之占有人或因果占有—推定本權合乎其占有（民法典第 1193 條及第 1175 條）。因此，訴訟法與民法協調（民法典第 1210 條），讓其有權提出第三人異議（民事訴訟法典 1292 條第 1 款）。

* 單純之事實持有人及按民法之規定，等同以他人名義占有之占有人（民法典第 1177 條），按規則不可提起第三人異議。

但對於某些以他人名義占有之占有人，民法例外地給予其保護占有之方法，其中包括第三人異議：例如，承租人（民法典第 982 條第 2 款）、借用人（民法典第 1061 條第 2 款）等。

占有以擔保物權為依據之占有人（質權人：民法典第 665 條：留置權人：民法典第 748 條），由於查封不侵害其占有，故其不具有提起第三人異議之正當性。

* 被執行人之配偶，只要其（在執行之訴中）具有第三人之地位。

* 其他因查封侵害其占有之第三人。

D. 請求返還所有物之訴（民法典第 1235 條）

屬被查封侵害權利之所有人提起之普通宣告之訴。

屬完全獨立於執行之訴訟程序之方法，且其可於任何時刻（參閱民法典第 1237 條）導致在執行之訴中之變賣被撤銷（第 803 條第 1 款 d 項）。所有具有與透過法院變賣財產不相容之權利之人，均具提起該種訴訟之正當性。

無須證明占有，但須證明實體之權利。

無任何期間限制（“相反解釋”第 803 條第 3 款）。

占有人或所有人可選擇地使用第三人異議或請求返還所有物之訴。

12.4 解除查封

為查封後之行為，其目的旨在終止查封之效力

出現非為執行之變賣後支付，而消滅執行之訴之原因時：在下列情況下，查封可透過法院之批示解除：

--違法查封：

--反對查封之理由成立：

--在下列情況下，請求查封之人得撤訴：第 720 條第 2 款 d 項，第 716 條第 2 款；

--物之消失：查封失效或賠償；

- 執行停頓逾六個月（第 733 條）；
- 部分解除查封—第 728 條第 212 款

12.5 縮短執行

A. 立即支付：第 767 條及第 770 條

作出查封後，在被查封之財產中可能存在一些金錢（或金錢之債權，及後被清償），而該等金錢可滿足請求執行之人之債權（及訴訟之費用）。在這情況下，得透過交付有關金錢，以便立即支付。

該工作亦可能須透過兌換某種貨幣之金錢為之。

B. 收益用途之指定（民事訴訟法典第 772 條及第 774 條及民法典第 654 條）

這為另一種簡化成縮短執行之形式，其透過指定被查封之財產之收益以滿足債權人之債權。

這形式僅透過請求執行之人之聲請為之。

有關之財產為不動產，或須登記之動產，又或記名之債權證卷時，方可以指定收益用途（民事訴訟法典第 772 條至第 774 條及民法典第 652 條）

13. 對債權人之傳召及對債權人之審定

13.1 個別執行及集體執行之制度

我們之制度不屬單純個別或絕對之執行制度（僅請求執行之人透過具推動之執行程序獲得債權之滿足）。然而，為何設立一原則，根據此原則所有財產變賣時解除所有擔保物權（民法典第 814 條第 2 款），故容許對於被查封之物具有物之擔保之債權人參與執行（第 755 條第 1 款 b 項）。

因此，這屬混合制度：

- 請求清償債權之債權人僅可以透過其具有擔保之被查封財產之價值，清償其債權（第 755 條第 1 款 b 項及第 758 條第 1 款）；
- 任何不損害擔保物權之執行之訴之結果，均無須該等債權人參與（第 756 條）；
- 優先受償權之債權人之行為限於其擔保物權。

13.2 傳喚

a)債權人（第 755 條第 1 款 b 項）；

具物之擔保之債權人；

公鈔局；

不被知悉之具物之擔保之債權人。

b)被執行人之配偶(第 755 條第 1 款 a 項)；

查封涉及請求執行之人不可自由轉讓之不動產時，配偶得就請求清償債權之債權人所具有之債權提出反駁。參閱民事訴訟法典第 62 條及第 63 條。這屬民法典第 1548 條中規定之情況。

請求執行之人使用民事訴訟法典第 709 條及其數款所規定之權能時。

屬不可擴及為夫妻兩人之債，因而不受強制延遲之規定約束時，請求執行之人得指定夫妻共有之財產。但在指定時，須請求傳喚被執行人之配偶，以便其欲聲請分產時，可聲請為之。

13.3 要求清償債權之要件（第 758 條）

要求清償債權之債權人必須：

對被查封之物具有物之擔保（第 758 條第 1 款）：

具有執行名義（第 758 條第 2 款）。

——倘擔保為於另一執行中之查封時（第 764 條），中止較遲查封之執行程序，且被中止之執行之聲請人將作為要求清償債權之債權人

參與首個執执行程序，以便滿足其債權。其債權未能於該執行中完全被滿足時，則重新進行被中止之執执行程序。

--侵權人就被查封之財產具物之擔保，但不具執行名義時，可聲請債權之順序排列等候其取得執行名義後方為之（第 762 條）

13.4 要求清償債權（第 758 條）

債權人應於傳喚後 15 日內，要求清償其債權（第 758 條第 2 款）。

由於屬一負擔，因此不要求清償債權時，一經變賣成判給將失去有關之物之擔保（民法典第 8 14 條第 2 款）

所有清償債權之各要求作成單一卷宗，以附文方式附於執行卷宗（第 758 條第 4 款）且按情況，依照宣告之訴之通常成簡易訴訟程序進行（第 761 條第 2 款 a 項），但具有下列分別：

- 該附文卷宗具有完全懲罰效力（第 761 條第 3 款）；
- 提出要求後為反駁（期限為 15 日）（第 759 條第 2 款）；
- 之後為對反駁之答覆（期限為 10 日）（第 760 條）；
- 再無其他之訴辯書狀（第 761 條）

下列各人可就要求清償之債權提出反駁（第 759 條第 2 款）：

- 請求執行之人，被執行人，配偶（被傳喚時）及任何對被援引

任何擔保物權所針對之財產具物之擔保之債權人。

13.5 對債權之審定及訂定其受償順位

在該附文卷宗之程序之終局裁判內必須進行下列之工作：

- a) 司法確認所請求清償之債權（審定債權）；或不作出確認；
- b) 對於已審定之債權，須按優先順序排列，排列先後順序（第 761 條第 1 款）

審定及訂定其受償順位須以判決為之

訂定其受償順位之規則為實體法之規則：參閱民法典第 599 條第 2 款，第 662 條第 1 款，第 682 條第 1 款，第 708 條，第 728 條，第 737 條及隨後規定，第 748 條，第 749 條及第 1908 條。

14. 變賣階段

民事訴訟法典第 779 條及隨後規定及民法典第 814 條及 816 條。

應將命令變賣之批示通知請求執行之人、被執行人及對所有對將變賣之財產具物之擔保且已請求清償債權之債權人（第 780 條第 4

款)。

14.1 執行中之變賣方式 (第 779 條)

A--司法變賣 (第 784 條)：

以密封標書之方式變賣 (第 784 條及第 796 條)。

B--非司法變賣：

直接變賣予有權取得某物之實體 (第 797 條)；

以私人磋商方式實行變賣 (第 798 條)；

以及在拍賣行變賣 (第 800 條)。

14.2 變賣之效果

--產生物權移轉之效力 (將被執行人之所有權轉讓)；

--債權效力 (支付價金) (第 795 條)。

任何稍後對被查封之財產所作之處分或使具負有負擔之行為，一經變賣有關財產，將全部不產生效力，而並非只在變賣前，僅對執行不產生效力。

* 有關擔保物權之效力：

不論有否登記，均失效。

* 有關享益物權之效力：

享益物權在登記查封後方登記時，其形成對執行不產生效力 (民法典第 809 條)，且因執行而失效。

該登記於登記查封前作出時，則查封不可擴大至該權利，因此該權利繼續存在

14.3 財產之判給：(支付階段)

a). 僅在證實投標人已完全支付有關價金及履行移轉財產時固有之稅務上之債務後，方將財產判給及交付投標人。(第 795 條)

b) 作出財產判給之批示後，須向取得人發出移轉憑證，而憑證中須指明有關財產之資料，並證明已支付有關價金及已履行稅務上債務，以及聲明將該財產判給取得人之日期。(第 795 條)

取得人得以上條所指之批示為依據，按執行交付一定物之規定，聲請對有關財產之持有人繼續進行執行情序。(第 796 條)

14.4 財產之贖回 (第 806 條)

實體法規範很多情況之優先權，即是說，在有償取得之行為中，某人有權利代替某物之取得人，由其履行取得人有權履行之負擔。

贖回權是在執行之變賣中，對被執行人之全部或部份財產之特殊優先權。

該權利首先賦予被執行人之配偶，其次為其卑親屬，最後賦予其尊親屬 (第 806 條第 1 款及第 809 條)。然而，無需像一般優先權人般，首先通知他們行使優先權。

15. 支付階段

方式 (第 765 條)：

1. 交付金錢

* 立即支付

--交付被執行人財產中之金錢，或已查封金錢之債權時，來自支付該債權之金錢（第 767 條）；

--透過判給財產抵銷所負起之債務以滿足（請求執行之人或請求清償債權之債權人）之債權（第 768 條及隨後規定）：

請求執行之人及要求清償債權之債權人可透過判給提議取得須在執行中變賣之財產。

在財產之判給中，請求執行之人或要求清償債權之債權人須作出一取得有關財產之聲請。後按以密封標書在法院變賣之方式進行。於無人提出其他較高價格之標書時，方接納其聲請。

3. 指定財產之收益。

4. 變賣財產之取得。（看第十四點）

* 間接支付：

第六章

執行之消滅

16. 執行之訴的消滅原因

消滅執行之正當方式是透過任何強制支付方式為之（民事訴訟法典第 810 條及隨後數條），然而，在下列情況下執行亦可消滅：

--有關債務（及訴訟費用之義務）之消滅，尤其是自願支付—執行之免除；或

--因其他消滅執行之訴之原因（執行之不正常消滅）-參閱第 229 條（訴訟程序之消滅原因），這亦適用執行程序，因為其載於民事訴訟法典第二卷，關於訴訟程序之一般規定。

第七章

判決

17. 執行之訴之終結。就裁定執行之訴消滅之判決提出之爭執

執行終結後，法官應作出一裁定執行之訴消滅之判決：

- 僅在支付訴訟費用後；
- 就該判決可提出上訴（第 817 條第 1 款 c 項）。

第八章

重開被消滅之執行之訴

18. 重開執行之訴之原因。
程序之手續

民訴訟法典第 814 條

* 原因：執行名義涉及相繼之單一給付之情況（第 814 條第 1 款）。

* 應已排列償其債權順序之債權人之聲請，而其仍未被支付。

* 無需重覆傳喚之行為，且對於執行之財產已進行之所有程序步驟均予以保留，但須就有關之聲請通知其他債權人及請求執行之人。

執行之訴之訴訟前提

——摘要——

執行之訴訟程序之正常形成及進行之基本要件—透過執行之訴旨在達到滿足債權人之利益（執行之訴之目的為實質彌補遭受侵害之權利（民事訴訟法典第 11 條第 3 條）。

--正如宣告之訴，訴訟前提可分為下列各類：

關於當事人之訴訟前提 1

1. 當事人能力—適用曾就宣告之訴中所學習之規定，而該等規定適用於所有訴訟（第 39 條）。

2. 訴訟能力—適用曾就宣告之訴中所學習之規定，而該等規定適用於所有訴訟（第 43 條及隨後規定）。

3. 正當性：形式正當性原則

A 規則：

在執行之訴中，正當性明顯屬一形式之概念。法律本身（第 68 條第 1 款）指出誰在執行名義中「顯示」為債權人，以及誰在執行名義中「具有債務人之地位。」²。為執行之訴中最重要之主當事人。但可在執行程序較後之階段中，出現其他主當事人：配偶及被執行人之優先債權人（第 755 條）。

B 例外：

a) 無記名證卷：

--為在第 68 條第 2 款規定之具邏輯之例外情況，例如：無記名之支票。票據之持有人應促進有關執行。其作為請求執行之人之正當性，僅須透過證明其作為持有人之身份予以確定。

b)權利或債之繼承人：

--第 68 條第 3 款所規定之情況，權利擁有人之繼承人得透過聲請提起執行之訴，聲請中須證明其繼承人資格，並指出繼承之創設事實，只要繼承於執行名義形成後，但於提起執行之訴前出現。繼承於提起執行之訴後出現者，則須透過繼承資格之附隨事項以證明繼承人之資格（第 301 條及隨後規定）。

c)具物之擔保之債權：

如具負擔之財產由債務人占有，則須按形式正當性之規則處理；

--如非由債務人占有，亦即是說，如由第三人占有有關財產，第 68 條第 4 款規定須針對具負擔財產之占有人提起執行之訴。

d)針對第三人之判決之可執行性（第 69 條）

--僅出現在交付一定物之執行中 — 第 69 條之規定包括下列情況（訴訟之附隨事項）；

* 民事訴訟法典第 215 條第 3 款 — 取得人不具有資格時（於在生時之移轉中，繼承資格為任意性），不參與訴訟，但透過一般制度，

判決之效力可對抗該人。例外 — 第 215 條第 3 款最終部份。

* 民事訴訟法典第 270 條 — 第三人之參與

因此，在該等情況下，不單可針對被判須作出給付之債務人提起執行之訴，亦可針對上述第三人為一形式正當性原則之例外情況。

e)代位之執行之訴：

--債權人可提起執行之訴針對其債務人之債務人。

但...

債權人得查封債務人對第三人所具有之債權，而該行為因使代位之訴訟變得不需要，因而減少對該形式正當性規則之例外情況之範圍。

C 特殊之情況

1. 法律賦予檢察院積極正當性³

民事訴訟法典第 70 條一對任何訴訟程序中規定繳納之訴訟費用及罰款之執行。

2. 在法院之代理之強制性

--在利益值高於中級法院之法定上訴利益限額之執行程序中（第 74 條第 1 款 c 項）

--在利益值低於中級法院但高於初級法院之法定上訴利益限額之執行程序中。然而在此種情況下僅在被執行人提出異議時，委託律師方屬強制性（第 74 條第一款 d 項）。

--在以附文併於執行之訴之審定債權程序中，只要所請求清償之債權之價值高於初級法院之法定上訴利益限額，且要求對其作出審定（第 74 條第 5 款）。

--在利益值高於初級法院之法定上訴利益限額之最初之結算程序中（雖然法律並無明示指出須具法院之代理，但事實上，該等訴訟程序為加插在執行之訴中之宣告之訴）。

--在就執行之訴所提起之上訴中：第 74 條第 1 款 b 項，其不區別訴訟種類。

3. 關於法院之訴訟前提

由民事訴訟法典第 21 條至第 25 條之特殊規定所規範。

II. 專門之訴訟前提

--對規範作為非常特殊之特徵之獨立訴訟法律關係之執行訴訟程序之形成及發展，所不可欠缺之要件。

--宣告之訴之根本及首要之目的為審判實質之問題，因而其訴訟前提是對實質問題之判決之要件：相反地，由於債權人已透過具執行力之執行名義獲得證明，故在執行之訴中，其根本及首要之目的為實質滿足被侵害之權利。

--執行之訴之專門訴訟前提之法律規範：民事訴訟法典第 12 條、第 677 條至第 683 條及第 686 條至第 694 條。

--將該等前提按下列之區分，具有重要意義：

- a)形式上之前提；及
- b)實質上之前提。

--執行之訴之專門訴訟前提與該訴訟之標的有密切之關係。執行之訴之標的是以執行名義確定的（第 12 條第 1 款），其為一形式上之前提。

因此，將執行之訴之專門訴訟前提分為：

a) 形式前提：執行名義（第 12 條及第 677 條至第 683 條）

* 作為執行之訴之依據，執行名義是產生執行程序之必要及足夠之條件：

1. 必要條件，因不可能有不具執行名義，無法律賦予執行力之任一書面文件之執行之訴（“nulla execution sine titulo”）⁴；

2. 足夠條件，因只要具有執行名義則可提起執行程序⁵。

* 一個執行名義可作為多於一個之執行之訴之依據。

* 就執行名義之法律性質存有多個學說：

1. 其中一個由 LIEBMAN 提倡，其注意內容方面—根據該學說，執行名義為法律行為本身，其包含了取得某權利之依據（內容方為重要）；
2. 另一個學說由 CARNELUTTI 提倡，其注重外在方面—根據該學說，執行名義為書面之文件，其強調形式方面。

3. 葡萄牙訴訟法律所採取之學說：為 CARNELUTTI 之學說，其可後對民事訴訟法典第 12 條第 1 款之閱讀和解釋中得知：法律行為表現在債務人之意思表示，其執行效力取決於結束有關法律行為之文件之形式方面，因為是形式之要件賦予執行名義證實有關權利之保障之地位⁶。

* 執行名義之分類（民事訴訟法典第 677 條，其列舉為盡數列舉之規定）⁷。僅法律所指者，方屬執行名義。

a. 1) 法院發出之執行名義（第 677 條 a 項）；

A. 給付判決

1. 裁定履行任何債之判決，而不單指在宣告之訴之給付之訴中所作之判決。

2. 已確定之判決，但第 678 條第 1 款所規定者除外。

B. 司法當局裁定履行一債之批示或其他裁判（第 679 條第 1 款）

C. 在澳門運作之仲裁庭之給付裁判，而該等裁判不須認可，即具執行之效力。

D. 審查及確認之判決—對澳門以外地區法院⁸所作之判決必須審查及確認方可在澳門執行（民事訴訟法典第 1199 條至第 1205 條），在此情況下，執行名義為確認及審查外國判決之裁判，而澳門以外地區之判決本身。

a. 2) 非由法院發出之執行名義（第 677 條 b、c 及 d 項）

A. 由公證員作成或認證，證明存有一債務⁹之文件。這裏包括：

1) 公證書；

2) 公證遺囑；

3) 具認證書之私文書（例如：密封遺囑，在此種遺囑中，須由公證員作成核准書）。

B. 無經認證之私文書（第 677 條 c 項），其可分為：

C. 按財產清冊作成之證明書：第 683 條規定之特殊情況，且產生兩方面之理解：

1) 似乎，嚴格地說，執行名義應為認可在財產清冊中所作之分割之判決；

2)該等證明書僅在執行之訴於與進行財產清冊之訴之法庭非為相同時，又或用作登記時方為必需者，或方具發出該等證明書之理由。如執行之訴須於相同之法院進行，則須將其卷宗併附於有關之財產清冊之訴之卷宗進行（第 21 條第 3 款）。

D. 於澳門以外地區作成之文件（第 680 條第 2 款）一無須審查，僅須符合發出有關文件所在地法律要求之要件即可。

II.1 欠缺執行名義或其不具執行力之後果¹⁰。

--對於由 LIEBMAN 倡導之學派之追隨者，由於執行名義為一行為，為取得權利之依據，執行名義作為訴因，故此，欠缺執行名義將不可避免地裁定最初之聲請不適當。

--按照葡萄牙民事訴訟法所採納之立場（CARNELUTTI 之論點），執行名義為文件，可出現兩種情況：

* 如果初之聲請中指出存有執行名義，但並無將該件一同提交——在此情況下，應作出補正批示，請請求執行之人在指定期間內提交該文件，否則裁定執行之訴消滅。

** 如無指出存有執行名義——法官應初端駁回最初之聲請，因為缺乏執行之訴必須之特別前提。且為法院依職權審理者，並可

認為透過第 375 條第 1 款之效力，適用第 375 條第 1 款。

然而…

法官不作出任一上述批示，且命令傳喚被執行人時，則在法律上如何解決？

-- 被執行人可提出異議（第 696 條）

然而…

如被執行人無作出任何之反應，則在法律上如何解決？

-- 法官至少可在變賣被查封之財產之日期前裁定執行程序消滅，因為有關之事宜屬法院依職權審理者。

*** 在*及**中所述者均適用於援引執行名義，且將之附於卷宗內，但不具有執行力情況 11。

b) 實質訴訟前提（債應具有之特徵，且具備有關前提與否須透過執行名義予以證明）

1. 債之確定及可要求履行（第 686 條至第 689 條）。

在執行之訴中，原告（請求執行之人）不可像在宣告之訴中般，提出仍未確定，仍不可要求履行或仍未確切定出之請求。

-- 透過執行名義，得知有關債毫無疑問是存在，又或其標的應已確定時為確定之債。

-- 債已到期時為可要求履行之債

-- 上述之概念應用於各種不同之債：

a)選擇之債及種類之債 -- 包括兩個或以上給付，但債務人僅須履行透過選擇被指定者以解除有關之債（民法典第 563 條第 1 款）。種類之債（民法典第 532 條及隨後規定）-- 在執行方面則以第 687 條及其數款予以規範。

b)條件之債（受中止條件限制）-- 當發生某一與當事人之意願無關之事情時（例如對於有限期之債，那不可阻止之時間之過去），變為實質及完整之潛在債務。在發生有關事情前，有關之債是不可請求者。

c)僅可就已到期，但無自願履行之債方可向法院提出請求，僅該等債可成為執行之訴之標的。

該規則有兩個例外情況：

1. 有關債務包括已到期之給付及其他將會因時間之過去而到期之給付時，已到期之給付以及在案件待決期間內到期者均為可請求之債（透過第 375 條第 1 款之效力而將 393 條第 1 款適用於執行之訴）；

2. 如到期與否僅取決於對債務人之催告，則可提起執行之訴，而有關之傳喚則視作催告。

2. 債之確切性（第 689 條至第 694 條）

--按照第 689 條及隨後規定，未確切定出之債（那些按照執行名義仍未能確定執行之金額或執行之標的為一集合物之債）之執行，仍須受結算這不可缺少之條件約束。

--法律規定了三種結算形式：

由請求執行之人，被執行人及仲裁員之結算（民事訴訟法典第 689 條，第 690 條及第 693 條）。

--執行包括仍繼續計算之利息（將到期之利息）時，根據第 689 條第 2 款之規定，有關之結算最後由法院辦事處為之。

--僅在執行中請求已到請求之利息時，請求執行之人應在最初之聲請中作出結算（須同時解釋第 689 條第 1 款及第 2 款之規定）。

3. 欠缺該等實質前提之後果

--有關之後果與制度與欠缺執行名義或執行名義不具執行力之後果及制度相同一初端駁回最初之聲請（補充適用第 394 條第 1 款 d 項最後之部份）。

--法官無作出該批示，並命令傳喚被告（被執行人）時，被告得反對有關之執行（第 697 條 c 項）或就傳喚之批示提起異議。

--被執行人不作出任何反應時，法官在較後程序中（至少在變賣被查封物前）亦可依職權審理欠缺該等前提之情況並裁判有關執行消滅。

I.

執行

上指詞語在法律及學理之用語方面之解釋也很廣範：

1. 為執行之訴之同義詞 — 訴訟法本身將執行之訴稱為執行。

例如：

--在民事訴訟法典第 21 條至第 25 條、第 68 條至第 71 條、第 74 條、第 677 條及隨後規定。

2. 意思為在執行之訴中提出之請求。例如：民事訴訟法典第 684 條及第 685 條其標題為「執行之自始合併」及「執行之繼後合併」。

3. 意思為執行之訴中其中一個行為：債務人或第三人財產之扣押。例如：第 704 條第 1 款。

4. 意思為一司法裁判之履行，表現為一些行為或一些進行之程序步驟，但其與正式之執行之訴並無伯日可關係。

這被稱為非正式之執行

例如：在有關之民事登記中以附註記錄離婚時，執行有關判決，然而在登記方面，就該判決不可提起執行之訴。

II.

在現行葡萄牙民事訴訟法典中之宣告之訴／訴訟程序及執行之訴／訴訟程序

簡述執行之訴獨立於宣告之訴之一些主要重點

正如宣告之訴一樣（民事訴訟法典第 11 條），執行之訴亦由提起訴訟開始。

然而：

--執行之訴並非宣告之訴之必然補充。

--宣告之訴與執行之訴為不同訴訟程序。

--如須進行執行之訴，則必須開始進行一新訴訟程序，且債權人應向法院提出聲請（民事訴訟法典第 695 條第 1 款）。

--兩種訴訟程序之訴訟前提並非完全相同。

--亦可邏輯地理解到兩者之程序步驟亦不同。

--另一方面，法官就初端駁回及邀請補正有關最初聲請方面之權力亦不同（民事訴訟法典第 394 條及第 695 條，前者透過第 375 條第 1 款之規定適用於執行之訴）。

--民法及商法普遍賦予之實體權利之完全及有效取得可單純透過宣告之訴達到、無需進行執行之訴，只要在被告自願履行法官之裁判且滿足原告之主張之情況下。

--下列情況，僅會進行宣告之訴：

a)原告針對被告提出一權利，但判決對其不利時裁定訴訟之理由不成立；及

b)確認之訴或單純之宣告之訴。作出判決後，再不需任何行為。在此情況下不得提起執行之訴，因為不可要求作出任何之給付，並無

裁判任何人滿足有關之給付。

--原告之權利雖無被判決宣告或確認，只要其持有一法律視為足夠或適當之文件作為執行之訴之基礎，則亦可只進行執行之訴。

III.

在執行之訴中使用不適當之訴訟形式之後果

A. 為民事訴訟法典第 145 條規定之情況。

B. 結果為將對被執行人之防禦構成妨礙之行為撤銷（第 145 條第 2 款），且該等行為屬不可利用之訴訟行為（第 145 條第 1 款）。

C. 在初端批示中，法官應證實請求執行之人所使用之訴訟形式是否符合有關執行之訴之目的及利益值；如不符合，則應立即命令作出確屬必需之行為，使訴訟程序之形式儘可能接近法律所規定者（第 145 條第 i 款）。

注釋：

1. 欠缺關於當事人之訴訟前提之結果視乎被法官作出裁判之時刻刻而有所

不同：在審查最初之聲請時立即作出，則應初端駁回聲請；在審查最初之聲請之後，被執行人在被傳喚後可援引該等訴訟前提，提出異議或就傳喚批示提出抗告。在異議或抗告中須援引該等瑕疵作為反對之依據。但結果並非駁回起訴（此為宣告之訴之專門概念），而應消滅有關執行。欠缺訴訟前提可按一般規定補正。

2.在此處，「債權人」及「債務人」具有廣泛含義。分別包括一債項之債權人或一項物權之擁有人及債務人，申言之，一債項之義務主體對一物權之侵犯人。

3.正如 Jacinto Rodrignes Basto 在其所著之《民事訴訟法典註釋》第一卷第 169 頁中貼切地強調，第 70 條之「目的並非訂定檢察院在執行之訴中之正當性，而僅是指定誰負責推動對在任何司法訴訟程序中規定繳納之訴訟費用及罰款之執行程序」。因此認為檢察院具有此特殊之正當性以執行訴訟費用及罰款，即使該等款項在宣告之訴中規定亦然。

4.不要將文件之執行力與其絕對之證明力混為一。兩者之概念不同。有些可執行之私文書不具有完全之證明力。

5.執行程序不可依職權提起，即使涉及履行由某主權機關發出之某一命令亦然。為單純之私人利益，由在宣告之訴中勝訴一方當事人提起執行程序（處分原則）。

6.因此，只要債權人擁有該文件，則可提起執行程序，即使該文件中所指之權利已不存在，更極端之情況為有些錯誤之權利！而在該等情況下，執行之訴開始進行，但債務人可使用法律賦予其之方法以證明有關訴訟只是基於一「憑空想像」之權利，即所謂之「不公正執行」。為此，債務人例如具有被執行人異議，正如我們所知，其為與執行之訴有聯繫，用作辯論

有關權利是否存，為具宣告之訴性質之程序。因此，原則上，執行之訴進行至提出異議，即使異議獲接納後（第 701 條第 1 款）。

7.因此透過雙方當事人間之協議將執行力賦予法律列舉之文件以外之文件為無效。然而，相反地，並不妨礙雙方當事人協議將法律賦予執行力之文件視為無執行力。

8.不論是常設法院或仲裁法院，更且，如屬後者，亦不論仲裁員是否葡籍人士一見《民事訴訟法要義》，Jacinto Rodrigues Bastos 學士第 1 冊第 149 頁。

9.支付一定金額、交付一定物或作出一事實之債。

10.該事宜之處理導致包括在本概要部份有關執行名義之法律性質之問題得以充份闡述。

11.可執行性，即是說向國家請求協助透過合適之訴訟程序強制履行所欠之給付之可能性。
